

1501927-17.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... de que pudesse ele também estar realizando o tráfico naquele local, mostrando-se aptos ao recebimento da denúncia, já agora, após o desenvolvimento de atividade cognitiva mais aprofundada, não se seguiram elementos probatórios que pudessem efetivamente amparar a imputação do tráfico.

Não basta à demonstração da prática do delito a indicação de elementos que evidenciem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501927-17.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501927-17.2021.8.26.0510 - 2021/000381

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REBERCON APARECIDO BRANDAO MELLE e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

REBERCON APARECIDO BRANDAO MELLE, conhecido como Nenê, e BRUNO LUIZ PINTO DA SILVA, conhecido como Geléia, qualificados no inquérito, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 09 de junho de 2.021, por volta das 17:00 horas, na Rua 17, nº 325, Bairro do Estádio, nesta Comarca, o primeiro vendeu 01 (um) eppendorff contendo a substância entorpecente que determina dependência física e psíquica denominada cocaína e, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o segundo, que concorria, de qualquer modo, para tal conduta, guardava e tinha em depósito outros 25 (vinte e cinco) eppendorfs contendo a mesma substância, totalizando com aquele outro peso líquido aproximado de 4,06 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 18/19 e laudo de

constatação preliminar de fls. 22/23, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que no dia 23 de junho de 2021, por volta das 15:50 horas, no mesmo local, BRUNO LUIZ PINTO DA SILVA, conhecido como Geléia, com intuito mercantil, guardava e tinha em depósito outros 02 (dois) microtubos contendo a substância entorpecente que determina dependência física e psíquica denominada cocaína, totalizando peso aproximado de 2,0 gramas, e 01 (uma) porção contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocannabinol, totalizando peso líquido aproximado de 2,0 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 127 e laudo de exame químico toxicológico a ser oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificados, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor dos acusados, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 09 de setembro de 2021. Em instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa, com posterior interrogatório dos acusados.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal em relação ao acusado Bruno e no mínimo legal em relação a Rebercon, agravando-se quanto a ambos os acusados em razão das recidivas, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime prisional inicial fechado. Requereu, ainda, o perdimento da quantia apreendida.

Já o ilustre Defensor, dizendo insuficiente a prova produzida no que diz com a posse, propriedade e a destinação mercantil do entorpecente, requereu a absolvição do acusado Bruno, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, em relação a ambos os acusados. Requereu, por fim, seja facultando aos acusados a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede em parte a pretensão acusatória.

Atribui-se aos acusados a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, REBERCON APARECIDO BRANDÃO MELLE vendeu o entorpecente indicado na denúncia e, ainda, agindo em concurso e com identidade de propósitos com BRUNO LUIZ PINTO DA SILVA que concorria, de qualquer modo, para tal conduta, guardavam e tinham em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 286/288, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em juízo, o acusado REBERCON APARECIDO afirmou que na ocasião dos fatos tinha rompido relacionamento com a esposa, por isto que havia alguns dias estava ocupando uma moradia localizada na rua 17, onde se reuniam usuários de entorpecente, negando tivesse levado para lá um fogão. Após ter ido a uma padaria, no momento em que retornava àquele imóvel, foi abordado por policiais civis, os quais ordenaram que abrisse o portão, mas antes de fazê-lo eles cortaram o cadeado. Negou que tivesse momentos antes realizado a venda de entorpecente a qualquer usuário naquele mesmo local, confirmando que o entorpecente apreendido no forro do telhado lhe pertencia.

Já o acusado BRUNO, que não se encontrava no mesmo local, recaído sobre ele denúncia de que estaria promovendo a venda de entorpecente por lá, acabou sendo preso temporariamente dias depois, apreendendo-se com ele uma chave de um cadeado que guarnecia um portão daquele imóvel onde realizada a prisão em flagrante do acusado Rebercon, observando, entretanto, que tinha encontrado esta chave na via pública, defronte à residência da genitora. Acrescentou que esteve uma vez naquele imóvel, onde deve ter deixado cair um mandado de intimação, que foi encontrado em

um dos cômodos, não reconhecendo como suas as roupas encontradas neste mesmo lugar, negando, outrossim, a realização do comércio ilícito. Todavia as versões deduzidas pelos acusados foram contrariadas pela prova produzida.

De fato, os Investigadores de Polícia ouvidos, reiterando em juízo o que exposto contemporaneamente aos fatos, disseram que na ocasião haviam denúncias de que um ponto de tráfico existente na rua 17 estava sendo comandado por um indivíduo conhecido por "Geléia" (o acusado Bruno). A verificar a veracidade daquelas denúncias, estiveram realizando observações no local e constaram que havia uma movimentação indicativa do comércio ilícito. Por conta disto, expedido mandado de busca e apreensão, e após o acompanhamento da venda de entorpecente a um usuário, este foi abordado, não sem antes ter jogado ao chão uma porção de cocaína, em seguida admitindo que a tinha adquirido naquele imóvel de pessoa conhecida por "Nenê" (o acusado Rebercon).

Diante da apreensão, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão, dirigiram-se ao imóvel e lá contataram o acusado Rebercon, o qual tardou em abrir o portão, por isto que cortaram o cadeado que o guarnecia. No interior do imóvel apreenderam uma balança de precisão, sobre o telhado duas porções de cocaína e no forro um "kit" contendo porções de cocaína, acompanhado de dinheiro trocado.

Ainda segundo o exposto, em um dos quartos do imóvel encontraram umas roupas e um mandado de intimação em nome do acusado Bruno. No curso da busca, esteve no local a esposa do acusado Rebercon pretendendo retirar um fogão que tinha sido levado para lá por ele, após terem se separado.

Posteriormente, alguns dias após, afirmaram os Policiais Civis que deram cumprimento a um mandado de prisão temporário expedido em desfavor do acusado Bruno, ocasião em que com ele foi apreendida uma chave que abria o cadeado do portão do imóvel localizado na rua 17 (cf. laudo pericial de fls. 183/186), apontado como sendo o local onde ele estava realizando o tráfico, inclusive apreendendo-se em um quarto roupas que foram retiradas pela irmã dele (Rafaela), além de duas porções de cocaína.

Como se tem consagrado, à míngua de qualquer elemento probatório que indique algum abuso, não se pode presumir que os policiais civis estivessem animados do propósito de incriminar indevidamente o acusado. Sobre isto: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Ademais, a emprestar ainda maior idoneidade ao que exposto pelos Investigadores de Polícia, na ocasião dos fatos o usuário que consta ter sido abordado confirmou ter adquirido a porção de cocaína apreendida em poder dele no referido imóvel, tendo sido o entorpecente fornecido pelo indivíduo conhecido como "Nenê", tratando-se do

acusado Rebercon, embora em juízo tivesse deduzida a inverossímil versão de que encontrara o entorpecente no chão, defronte à própria moradia.

Do que vem de ser exposto, tem-se certo que o acusado Rebercon estava ocupando havia alguns dias o imóvel localizado na rua 17, tratando-se de ponto de venda de entorpecente. No local havia inclusive um fogão que a esposa dele procurou recuperar quando tomou conhecimento da prisão em flagrante. Também se demonstrou que ele realizou a venda de uma porção de cocaína a usuário que foi abordado logo em seguida, indicando ter adquirido o entorpecente de "Nenê" (Rebercon). Igualmente se evidenciou, por relato do próprio acusado, que o "kit" com entorpecentes encontrado no forro do telhado a ele pertencia, a possibilitar suficiente juízo de convicção sobre a imputação da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, em relação ao acusado Bruno, a situação é diversa. Conquanto houvesse denúncia de que ele estaria realizando a venda de entorpecentes no local, tal fato, não obstante a informação de que por lá teriam sido realizadas algumas "campanas", não foi suficientemente evidenciado. É verdade que, posteriormente, com ele foi apreendida uma chave que abria o cadeado do portão do imóvel, como também localizadas algumas roupas que a irmã cuidou em recolher, mas se isto constitui indícios de que pudesse ele também estar realizando o tráfico naquele local, mostrando-se aptos ao recebimento da denúncia, já agora, após o desenvolvimento de atividade cognitiva mais aprofundada, não se seguiram elementos probatórios que pudessem efetivamente amparar a imputação do tráfico.

Não basta à demonstração da prática do delito a indicação de elementos que evidenciem estar ele ocupando o imóvel, assim por possuir a chave do cadeado do portão ou pelo fato de existirem roupas dele no local. É que as informações sobre a venda de entorpecente no local poderiam decorrer de atividade do acusado Rebercon, que como se viu também estava ocupando o mesmo imóvel.

Deste modo, não se ignora a existência que concorrem em desfavor do acusado Bruno, como dito, mas o conjunto probatório em relação a ele se mostra precário, ensejando dúvida sobre a realidade da imputação inicial, impondo-se, portanto, a desclassificação daquela para a infração prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao acusado Rebercon.

A pena-base deve ser agravada, entretanto, em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva (fls. 25/26), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

De outra parte, operada a desclassificação em relação à imputação dirigida ao acusado Bruno, passo à aplicação da medida correspondente.

Considerando o disposto o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Tóxicos, e diante da observação de que o acusado era usuário de entorpecente, em situação de drogadição, mostra-se adequada a imposição da medida educativa de comparecimento a programa ou curso de prevenção ao uso de entorpecente, pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, em consequência:

(i) com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado REBERCON APARECIDO BRANDÃO MELLE à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do

acusado, corrigido desde a época do fato; e

(ii) com fundamento no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado BRUNO LUIZ PINTO DA SILVA à medida educativa de comparecimento a programa ou curso de prevenção ao uso de entorpecente, pelo prazo de 5 (cinco) meses, em local a ser definido em execução, com a garantia de cumprimento prevista no §6º, daquele dispositivo, fixada a multa, em caráter sucessivo à admoestação verbal, em 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao acusado Rebercon, deve ser considerada a recidiva e também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras. Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: “O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de

flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008). E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado Rebercon na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA